

1502994-36.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: Denise Gomes Bezerra Mota

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/01/2022

... podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

E ainda, mesmo que o réu seja usuário de drogas, tal fato não afasta, necessariamente, a prática do delito de tráfico, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de substâncias ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

1ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11440-550

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502994-36.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502994-36.2021.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247270/2021 - DEL.POL.GUARUJA, 20177203 - DEL.POL.GUARUJA, 4578/21/203 - DEL.POL.GUARUJA, 2247270 - DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN ALCANTARA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Denise Gomes Bezerra Mota

Vistos.

Luan Alcântara Santos, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 11 de setembro de 2021, por volta das 15:00 horas, na Avenida São João, altura do nº 596, Paecará, nesta cidade e Comarca de Guarujá, durante a pandemia da Covid-19, em ocasião de calamidade pública, tinha em depósito e guardava, para a entrega ao consumo de terceiros, drogas consistentes em vinte e seis porções de cocaína, consoante o auto de constatação preliminar de fls. 11, o auto de exibição e apreensão de fls. 12 e a fotografia de fls. 19, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foi juntado aos autos o laudo de exame químico toxicológico realizado nas drogas apreendidas (fls. 98/100).

O réu foi notificado (fls. 83) e apresentou defesa prévia (fls. 86/87), que não foi acolhida e a denúncia foi recebida (fls. 101/102).

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 138) e o réu interrogado (fls. 139). Foi declarada encerrada a instrução e as partes não requereram diligências (fls. 139).

O representante do Ministério Público, nos debates, requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia, argumentando que a autoria e a materialidade restaram provadas durante a instrução criminal (fls. 139/144).

Nos debates, a defesa do réu requereu a improcedência da ação nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso, requereu a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, "j", do CP, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a concessão ao réu do direito de apelar em liberdade (fls. 145/146).

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

Com efeito, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, pelo laudo de constatação preliminar de fls. 11, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12, pela fotografia de fls. 19, pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 98/100, bem como pela prova oral coligida nos autos.

A autoria do réu também restou incontroversa pelas provas produzidas durante a instrução criminal.

Interrogado em juízo, o réu negou a autoria dos fatos. Disse ser usuário de drogas e as drogas apreendidas eram destinadas ao seu consumo. Na data dos fatos estava na frente de um bar onde pessoas usuárias de drogas costumam ficar. Tinha comprado as drogas mais à frente de um traficante chamado "Bebê", que possui as mesmas características do interrogando. Estava sentando bebendo e usando drogas quando avistou a viatura. Então, deixou as drogas de lado. Não tentou correr ou se evadir da viatura. Apenas saiu andando. Foi abordado e os policiais perguntaram se o interrogando tinha passagem. O policial Marcos Reis já havia prendido o interrogando em 2015. Os policiais encontraram as drogas onde o interrogando estava sentado. Não estava traficando. Pagou R\$ 130,00 pelas vinte e seis porções de drogas. Comprou grande quantidade de drogas para não precisar comprar drogas constantemente. Recebe auxílio emergencial e aluguel da casa que a sua mãe deixou de herança (fls. 139).

No entanto, as provas produzidas nos autos demonstraram o inequívoco envolvimento do acusado no tráfico de drogas e não foi apresentada situação capaz de excluir o crime ou isentá-lo de pena.

Senão vejamos.

O policial militar Marcos Antonio dos Reis, no seu depoimento judicial, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento quando uma pessoa parou a viatura e disse que na Rua São João havia um indivíduo negro e alto praticando tráfico de drogas. Deslocaram-se até o local e encontraram o réu agachado. Ao avistar a viatura, o réu tentou se evadir, mas foi detido. Com o réu foi encontrado R\$ 14,00 no bolso. O réu tentou se evadir e pediram apoio para contê-lo. No local onde o réu estava agachado foi encontrada uma sacola contendo entorpecentes. Quando o réu viu que o depoente encontrou a sacola de drogas, tentou se evadir novamente, mas foi detido. Não conhecia o réu anteriormente. O local em que o réu estava é conhecido pelo tráfico de drogas (fls. 138).

Erick Portas, policial militar, em juízo, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento quando uma pessoa parou a viatura e disse que um rapaz negro, magro e alto estava traficando drogas e escondia as drogas em um jardim que tinha pneus. Foram até o local e viram o réu, que possuía as mesmas características informadas, agachado no pneu mexendo em algo. Quando viu a viatura, o réu saiu andando e foi

abordado. O réu ficou reclamando durante a abordagem. Com o réu foi encontrado dinheiro, cerca de R\$ 14,00. Pediram apoio de outra viatura e quando a viatura chegou foram até o local onde o réu estava agachado. No local encontraram uma sacola com drogas. Quando viu a localização das drogas, o réu tentou correr, mas foi detido. Não conhecia o réu anteriormente. Já recebeu outras denúncias de ocorrência de tráfico no local em que o réu foi encontrado (fls. 138).

Ressalte-se que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois não se pode presumir a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de delito, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial. Ademais, não restou comprovada qualquer razão concreta de suspeição.

A propósito, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que:

"[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, [...]". (STJ, HC 496335 / SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

"[...] O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova [...]" (STJ, HC 471082 / SP, Rel. Ministro Felix Fischer, j. 23/10/2018, DJe. 30/10/2018).

Ora, diante dos depoimentos dos policiais e da prova material apreendida, sem dúvida o réu tinha em depósito e guardava os entorpecentes apreendidos e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda. Tem-se que diante do contexto fático em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta do réu, que estava em local conhecido pela venda de drogas, diante da quantidade dos entorpecentes encontrados com o réu, incompatíveis com o uso, restou comprovada a conduta típica do réu narrada na inicial acusatória.

Portanto, diante das provas produzidas, a autoria do delito é indiscutível. É certo que o réu guardava e tinha em depósito os entorpecentes e os entorpecentes eram destinados para o consumo de terceiros, ou seja, para a venda, ante a conduta do réu narrada pelos policiais, destacando-se que o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 descreve condutas variadas, podendo ficar configurado o delito de tráfico de drogas ainda que o agente não tenha sido surpreendido praticando atos de comércio, como no presente caso.

E ainda, mesmo que o réu seja usuário de drogas, tal fato não afasta, necessariamente, a prática do delito de tráfico, pois, como é sabido, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de substâncias entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

A propósito:

"(...) Ademais, a condição de usuário de drogas não exclui a de traficante, sendo infelizmente comum a mercancia realizada por usuários com o intuito de financiar seu vício (...)" (TJSP, Apelação nº 0000136-06.2016.8.26.0626, 5ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Damião Cogan, julgado em 10/05/2019).

Por fim, o crime de tráfico imputado ao réu restou consumado, restando evidenciado que os entorpecentes apreendidos com o réu eram destinados à venda e ao consumo de terceiros.

Definida a conduta do réu, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando os critérios do artigo 59 do Código Penal, e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, que o réu agiu com dolo normal à espécie e as circunstâncias e consequências do delito não extrapolaram os limites inerentes ao próprio tipo penal, fixo a pena-base no mínimo legal: 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência do réu (fls. 28/29), aumento a reprimenda em 1/6, perfazendo em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Ainda na segunda fase, deixo de reconhecer a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. No caso dos autos verifica-se que o estado de calamidade, em vigência desde o dia 20 de março após a publicação do Decreto Legislativo nº 6/2020, em razão da pandemia do Covid-19, em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito. Para a configuração da agravante, deve, pois, existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva. E, no caso dos autos, não restou comprovada a presença de qualquer facilidade para o cometimento do delito decorrente da situação de calamidade.

Na terceira fase, entendo não ser o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Isso porque, para sua aplicação, além do preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo penal (agente primário e de bons antecedentes), deve ficar demonstrado que o réu não se dedica a atividade criminosa e nem integra organização criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que o réu agiu de forma ocasional. Tem-se que a intenção do legislador, ao permitir a redução das sanções penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele eventual. No caso dos autos, verifica-se que o réu é reincidente (fls. 28/29), circunstância impeditiva da aplicação do redutor. Ainda, as circunstâncias dos fatos demonstram que o réu fazia do tráfico de drogas meio de vida.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, sendo que o valor do dia multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado, por entender ser o regime adequado à conduta do réu, que demonstrou se dedicar a atividade criminosa.

Ressalte-se que, considerando a pena definitiva aplicada, bem como a gravidade do delito, não são cabíveis os benefícios da substituição da pena ou da suspensão condicional da pena.

Por fim, considerando que o réu é reincidente, não é possível neste momento apreciar se o réu faz jus à progressão de regime prisional, de forma que eventual progressão de regime será apreciada oportunamente pelo juízo da execução. Destaco que as alterações trazidas pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o § 2º, ao artigo 387 do CPP, não revogaram os dispositivos da LEP, que devem ser considerados para a progressão de regime prisional. Logo, para a progressão de regime não basta apenas a consideração do tempo de prisão provisória, devendo ser preenchidos os requisitos legais dispostos na LEP.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra Luan Alcântara Santos para CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado não poderá apelar em liberdade. De fato, preso em flagrante assim permaneceu durante toda a instrução e, agora, com a presente condenação, mais razão ainda para permanecer custodiado. Trata-se de crime extremamente grave e se o réu aguardar o direito de recorrer em liberdade poderá não ser encontrado para a aplicação da presente decisão, tornando-a inócua. Ainda, em liberdade, o réu poderá reiterar a prática de condutas ilícitas. Recomende-se o réu na prisão em que se encontrar.

Nos termos da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial determinando-se a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas, preservando-se contraprova. Após o trânsito em julgado, determino o perdimento do dinheiro apreendido (R\$ 14,00), tendo em vista que as provas produzidas nos autos demonstraram se tratar de produto de tráfico ilícito de entorpecente. Providencie-se o necessário.

No que tange as custas processuais, diante da nomeação de Defensor Público Estadual, tem-se que foi deferida tacitamente assistência judiciária gratuita ao réu. E sendo assim, fica suspenso o pagamento das custas, nos termos do disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

Publique-se, intime-se e comunique-se.

Guaruja, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA